

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/10677

Acusada: União Federal

Ementa: Suposto exercício abusivo do poder de controle por parte da União Federal. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, afastar a arguição da defesa de que não estariam presentes os requisitos necessários para a configuração de condutas omissiva e abusiva de poder do acionista controlador.
2. Ainda em fase preliminar, destacar que, como a SEP excluiu do seu Termo de Acusação a imputação originalmente feita à União de infração ao art. 238 da Lei nº 6.404/76, não cabe ao Colegiado a apreciação e o respectivo julgamento de acusação que não mais consta da peça acusatória.
3. No mérito, ABSOLVER a União Federal da acusação de abuso de poder, em suposta infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Proferiu defesa oral o Procurador da Fazenda Nacional, Alexandre Cairo, representante da União Federal.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Pablo W. Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Gustavo Tavares Borba declarou-se impedido de participar da Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/10677

Acusada: União Federal

Assunto: Apurar a responsabilidade da União Federal, na qualidade de acionista controladora da Petróleo Brasileiro S.A., por infração ao artigo 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

RELATÓRIO

I. Do OBJETO

1. Trata-se de Termo de Acusação, elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face da União Federal, na qualidade de acionista controladora da Petróleo Brasileiro S.A. ("**Petrobras**"), por impor à companhia custos de subsidiar a geração de energia elétrica, por meio da omissão diante da reiterada inadimplência da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. ("**Amazonas Energia**") e da posterior novação da dívida resultante dessa inadimplência, em termos desvantajosos para a Petrobras, em dezembro de 2014.

II. Dos FATOS

2. Em 01.06.2006, a Petrobras celebrou os seguintes contratos de compra e venda de gás ("**Contratos**")¹:

(i) Contrato Upstream (celebrado entre o fornecedor de gás e a distribuidora de gás) com a Companhia de Gás do Amazonas ("**Cigás**"), sociedade de economia mista concessionária exclusivamente responsável pela distribuição de gás no Estado do Amazonas, conforme art. 25, §2º, da Constituição Federal². Neste contrato, figuraram como intervenientes a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("**Eletrobras**") e sua subsidiária integral, Amazonas Energia; e

(ii) Contrato Downstream (celebrado entre a distribuidora de gás e seus clientes) com a Amazonas Energia, por meio do qual a Cigás revende a esta última o gás fornecido pela Petrobras, para fins de geração termelétrica. Neste contrato, a Petrobras e a Eletrobras figuraram como intervenientes, sendo esta última fiadora e devedora solidária das obrigações contraídas pela Amazonas Energia.

3. De acordo com os Contratos, uma vez caracterizado o inadimplemento da Amazonas Energia com a Cigás, os créditos desta última contra a Amazonas Energia seriam cedidos em favor da Petrobras. Nesse contexto, dado o inadimplemento, a partir de janeiro de 2011, da Amazonas Energia com a Cigás, a Petrobras passou a ser a detentora dos referidos créditos, garantidos pela Eletrobras³.

4. Segundo apurado, a Amazonas Energia não possuía recursos para adimplir suas obrigações com a Petrobras por dois motivos principais: (i) os Fundos Setoriais⁴ não realizaram integralmente as devidas transferências que seriam direcionadas ao financiamento de geração de energia elétrica nos denominados Sistemas Isolados, localizados em sua maior parte na região Norte do país; e (ii) a Eletrobras não se dispôs a investir recursos, na sua subsidiária integral, que fossem suficientes para compensar a indisponibilidade orçamentária dos Fundos Setoriais⁵.

5. Em 31.12.2014, a Petrobras e a Amazonas Energia celebraram "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" ("**Instrumento de Confissão de Dívida**"), no qual esta última reconheceu dever à Petrobras a quantia de R\$3,26 bilhões, em

valores atualizados até 05.12.2014⁶, referentes ao fornecimento de gás entre fevereiro de 2013 e novembro de 2014 (fls. 20/25).

6. Nos termos do Instrumento de Confissão de Dívida, na qual a Eletrobras figurou como Interveniente-Anuente, a Amazonas Energia comprometeu-se a liquidar a dívida junto à Petrobras em 120 prestações mensais e consecutivas (vencendo a primeira em 20.2.2015), atualizadas pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais – SELIC, sendo ainda estabelecido que a União prestaria “garantia fidejussória irrevogável e irretratável”. Tal garantia, contudo, era vinculada à contragarantia que deveria ser outorgada à União pela Eletrobras e pela Amazonas Energia até 15.2.2015, caso contrário, passaria a Eletrobras à condição de fiadora e devedora solidária da dívida (cláusulas segunda e quarta).

7. Entretanto, a referida garantia a ser prestada pela União não foi efetivada, nos termos relatados na Carta Presidência 005/2015, de 14.1.2015, referente à “Dívida do Sistema Eletrobras com o Sistema Petrobras”, enviada pela Petrobras ao Ministro Chefe da Casa Civil, com cópia para os Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia, da qual se destaca o que se segue (fls. 90/92):

“Em 31/12/2014, a Petrobras e a BR, enquanto credoras, celebraram os CCDs [Contratos de Confissão de Dívida] com as empresas do Sistema Eletrobras, com garantia da União, por meio do qual foi equacionada a dívida do Sistema Eletrobras com o Sistema Petrobras, acumulada até 05/12/2014, no âmbito das dívidas supracitadas.

(...)

Parte da garantia da União (...) está condicionada à efetivação da contragarantia da Eletrobras (penhor de ações detidas pela Eletrobras em favor da União) (...)

Caso a contragarantia da Eletrobras não seja efetivada até 15 de fevereiro de 2015, a Eletrobras passará a ser garantidora do CCD no lugar da União, além de devedora solidária.

Adicionalmente, em que pese o CCD e as garantias com a União já terem sido assinados por todas as partes (Petrobras, BR, Sistema Eletrobras e STN) em 31 de dezembro de 2014, até o momento as vias das garantias que devem ficar na posse do sistema Petrobras não foram entregues pela União, sob alegação que na data da celebração dos instrumentos contratuais a Petrobras se encontrava inscrita no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN (...) Não obstante o reconhecimento pelo Sistema Eletrobras da dívida em aberto junto a Petrobras até 05 de dezembro de 2014, e o reconhecimento da dívida em aberto junto a BR até 30 de novembro de 2014, via celebração do CCDs, as empresas do Sistema Eletrobras continuam não efetuando o devido pagamento pelos fornecimentos realizados pela Petrobras após 05 de dezembro de 2014, e pela BR após 30 de novembro de 2014.

(...)

Quanto à estratégia de monetização do CCD, vale registrar que o então Secretário do Tesouro Nacional propôs ao Banco Nacional do Desenvolvimento Nacional (“BNDES”) que adquirisse a garantia pelo valor de face, sendo que, para tanto, a União deveria fazer um aporte no BNDES no valor garantido (...)

Todavia, diante da alteração na equipe do Ministério da Fazenda, ocorrida em janeiro de 2015, há incertezas acerca da manutenção da estratégia acima, o que impactará fortemente os planos da Petrobras de monetizar os recursos garantidos pela União e deixará de contribuir para o fortalecimento do caixa da Petrobras em 2015.

Em face do exposto, vimos por meio desta dar ciência dos fatos a V.Ex^a. e solicitar seu apoio no sentido de implementar os termos já acordados entre as partes, conforme explicitado na presente.”.

8. Diante disso, segundo informação prestada pelo DRI da Petrobras à fl. 60, em 03.3.2015 foi realizada reunião com representantes do Tesouro Nacional, do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da Eletrobras e da Amazonas Energia, onde ficou acordado que, em substituição à garantia da União, seria celebrado "Contrato de Penhor em Garantia" por meio do qual seriam penhorados em favor da Petrobras os créditos detidos pela Amazonas Energia junto à Conta de Desenvolvimento Energético ("CDE")⁷.

9. De fato, em 23.3.2015 a Amazonas Energia e a Petrobras celebraram "Contrato de Penhor em Garantia", referente ao penhor em favor da Petrobras do valor de R\$851,4 milhões decorrentes dos denominados "Contratos de Confissão de Dívida da CDE", celebrados entre a Amazonas Energia e a CDE com o objetivo de repactuar a dívida desta última perante aquela companhia⁸, referente ao atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.111, de 2009 (fls. 31/33v). Igualmente foi celebrado aditivo ao Instrumento de Confissão de Dívida (fls. 26/28), para fins de refletir a garantia em tela e a condição de fiadora e devedora solidária da Eletrobras exclusivamente quanto ao montante restante da dívida (R\$2,4 bilhões).

10. Posteriormente, em maio de 2015, foi celebrado aditivo ao "Contrato de Penhor em Garantia" (fls. 34/35), aumentando para R\$2,1 bilhões o valor dos créditos detidos pela Amazonas Energia em face da CDE, e penhorados a favor da Petrobras. Deste modo, foi celebrado segundo aditivo ao Instrumento de Confissão de Dívida (fls. 29/30v), para fins de refletir o acréscimo na garantia e a condição de fiadora e devedora solidária da Eletrobras exclusivamente quanto ao montante restante (R\$1,11 bilhão).

11. No entender da SEP, o Instrumento de Confissão de Dívida firmado entre a Petrobras e a Amazonas Energia caracterizou, em verdade, uma novação das dívidas inadimplidas. De acordo com a área técnica, primeiramente, porque foi celebrado novo contrato entre a Companhia e a Amazonas Energia, indicando o ânimo de novar a dívida existente e, como sabido, a confissão de dívida depende apenas da declaração do devedor, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil (então vigente)⁹, sem a intervenção do credor. Segundo, porque se o negócio fosse confissão de dívida, incapaz de alterar obrigações do contrato de compra e venda original, as partes não poderiam, por exemplo, ter estabelecido o prazo de dez anos para a quitação do débito, como foi realizado.

12. A área técnica destacou ainda que a própria Petrobras, por meio de seu Diretor de Relações com Investidores – DRI, informou que os representantes do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia participaram da negociação do Instrumento de Confissão de Dívida (fl. 18).

13. A SEP ressaltou que tais fatos, que seriam incontroversos e de conhecimento público, foram também descritos no item 3.3 do Relatório de Administração da Eletrobras referente ao exercício de 2014, abaixo reproduzido (fls. 178/179):

"Cabe ressaltar, ainda, no âmbito do segmento de distribuição, que a região norte do Brasil, onde estão localizadas algumas das empresas de distribuição da Eletrobras, por suas características geográficas, áreas extensas e baixa concentração populacional, distinguem-se das demais regiões, pois tem o seu abastecimento de energia elétrica suprido pelas termoeletricas movidas a diesel e óleo combustível, cujo custo é significativamente mais elevado.

De acordo com a Lei nº 12.111/2009, a Conta de Consumo de Combustíveis – CCC passou a reembolsar, a partir de 30 de julho de 2009, o montante igual à diferença entre o custo total de

geração da energia elétrica, para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada – ACR do Sistema Interligado Nacional – SIN, conforme regulamento.

Com a desobrigação de recolhimento da quota da RGR estabelecido pela Lei nº 12.783/2013, os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE passaram a ser transferidos à Reserva Global de Reversão – RGR e à CCC, para atender às finalidades das referidas contas. No entanto, as transferências dos recursos da CDE para a CCC não foram suficientes para cobertura de todos os montantes previstos para reembolsos das empresas de distribuição beneficiadas pela Lei nº 12.111/2009.

Considerando que o referido subsídio é parte considerável na formação do caixa das referidas empresas de distribuição, e devido ao alto custo do combustível necessário para atendimento do sistema isolado, que tem base de geração termoeletrica, essas empresas acabaram deixando de honrar algumas dívidas decorrentes do fornecimento de combustível junto à Petrobras Distribuidora S.A ("Br. Distribuidora") e à Petróleo Brasileiro S.A ("Petrobras"), no montante de cerca de R\$ 8,6 bilhões, data base de 05 de dezembro de 2014.

No entanto, no ano de 2014, foram celebradas pelas empresas de distribuição do Amazonas, Acre, Rondônia e Boa Vista, repactuações dessas dívidas junto às supramencionadas fornecedoras, sendo importante destacar que essas dívidas já estavam contabilizadas nas Demonstrações Financeiras das citadas distribuidoras. As dívidas serão pagas em 120 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela em fevereiro de 2015, sendo o saldo devedor corrigido pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia ("Selic").

Neste aspecto, importante destacar que o parágrafo quarto do artigo 36 do Decreto nº 4.541/2002, com a nova redação dada pelo Decreto nº 8.370/2014, e com a Portaria Interministerial dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda nº 652/2014, autorizou, por outro lado, a celebração, pelas empresas de distribuição, de Termos de Confissão e Repactuação de Dívida da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, em condições semelhantes àquelas praticadas para as repactuações firmadas com a BR Distribuidora e a Petrobras. Assim, por meio dessas repactuações com a CDE, o referido fundo setorial reconheceu ser devedor, perante as referidas empresas de distribuição, no montante de R\$ 6,1 bilhões, já homologados pela ANEEL, permitindo que os recursos provenientes desses créditos sejam utilizados para quitação das parcelas das dívidas com a BR Distribuidora e a Petrobras."

III. DA ACUSAÇÃO

14. De início, a SEP consignou que, a seu ver, o uso dado à Petrobras frente aos objetivos que justificam a sua criação seria no mínimo controverso, ainda que tal controvérsia não alcance a imputação ao final atribuída à União no Termo de Acusação.

15. Como registrado nos itens 13 a 22 do Termo de Acusação, a SEP, originalmente, concluiu pela violação ao disposto no art. 238 da Lei nº 6.404, de 1976¹⁰, segundo o qual a sociedade de economia mista não pode ser instrumento de satisfação de interesse público diferente daquele que justifica a sua existência. Em linhas gerais, a SEP concluiu que não seria atribuição da Petrobras manter hígida a distribuição de energia elétrica na região norte do país, considerando que o objetivo de sua criação, nos termos da Lei nº 2.004, de 1954, foi promover o abastecimento nacional de petróleo e seus derivados e o aproveitamento de outros carbonetos.

16. Entretanto, por ocasião da análise de que trata o art. 9º da Deliberação CVM nº 538¹¹, de 2008, a Procuradoria Federal Especializada da CVM ("PFE") divergiu desse entendimento, destacando que a Lei nº 2.004, de 1954, que criou a Petrobras, foi revogada pela Lei nº 9.478, de 1997, a qual teria instituído novo marco regulatório para o setor de petróleo e gás, redefinindo o objeto da Petrobras, para nele incluir quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidas em lei. Nesse sentido, a PFE concluiu que não teria havido desvio da Petrobras em

relação aos fins que justificam sua criação e existência e, portanto, infração ao art. 238 da Lei nº 6.404, de 1976.

17. Por sua vez, a SEP acolheu o parecer da PFE quanto à supressão da acusação de violação ao citado art. 238, porém optou por manter registrado no Termo de Acusação a controvérsia em questão, sob o argumento de que poderia o Colegiado, se julgar conveniente, considerá-la em sua decisão (itens 9 e 10 do Memorando nº 57/2015-CVM/SEP/GEA-3, às fls. 240/241).

18. Ainda de acordo com a SEP, independentemente da controvérsia acima, restaria evidente que o uso da Petrobras ter-se-ia dado em termos financeiramente desvantajosos para a companhia.

19. No entender da SEP, a Petrobras não somente possuía o direito de cobrar em Juízo os créditos que detinha contra a Amazonas Energia, como também detinha considerável poder de barganha para buscar o pagamento sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Todavia, prossegue a SEP, a Petrobras manteve durante longo período o fornecimento de gás sem qualquer contrapartida, tendo aceito a novação da dívida em condições que lhe seriam desvantajosas. Segundo a SEP:

"(...) para que a novação fosse financeiramente vantajosa para a Companhia, a nova dívida deveria ter valor presente igual ou superior ao daquela que foi substituída. E não é o que ocorre: a nova dívida – a ser paga em parcelas durante dez anos e remunerada pela taxa SELIC – possui valor presente líquido inferior aos R\$ 3,26 bilhões da dívida substituída, que era líquida e exigível em dezembro de 2014.

32. Isso porque a taxa de desconto da dívida da Amazonas Energia deve ser, necessariamente, superior à remuneração dos financiamentos diários lastreados em títulos públicos federais que servem de referência para o cálculo da taxa SELIC, dado que o risco de crédito da Amazonas Energia e de sua controladora – a Eletrobrás – é superior ao da União¹²."

20. A SEP também observou que, por ocasião da novação da dívida, a única garantia existente era aquela pessoal prestada pela Eletrobrás, pois a possível garantia da União dependia ainda da sua efetiva prestação até 15.02.2015, o que acabou não acontecendo. Especificamente, não havia tampouco garantia real que pudesse melhorar a qualidade do crédito quando a Companhia aceitou a novação da dívida, na medida em que o Contrato de Penhor em Garantia só foi celebrado em março de 2015.

21. Desse modo, a SEP concluiu que *"a transferência de riqueza que ocorreu da Companhia para a Amazonas Energia, com a novação da dívida em 31.12.2014, é igual à diferença entre os R\$ 3,26 bilhões e o menor valor presente líquido da nova dívida"*.

22. Especificamente quanto o argumento da Petrobras no sentido de que a cobrança da taxa SELIC em relação à dívida da Amazonas Energia seria justificada pelo art. 406 do Código Civil¹³, conforme interpretado pela jurisprudência¹⁴, a SEP manifestou o entendimento de que não se pode depreender do citado dispositivo que os juros moratórios devam ser sempre a taxa SELIC ou, muito menos, que essa taxa possua qualquer respaldo legal privilegiado em relação a outras taxas de remuneração. Ademais, a SEP reiterou que o negócio jurídico celebrado em 31.12.2014 seria uma novação, e não uma confissão de dívida, como defendido pela Petrobras, de sorte que não seria possível afirmar que a taxa de juros necessariamente deveria ser a original.

23. Por último, a SEP concluiu que *"o uso da Petrobras em desacordo com a legislação ocorreu em benefício a sua acionista controladora, a União Federal."*

24. Na visão da SEP, a transferência de valores da controlada direta (Petrobras) para a controlada indireta (Amazonas Energia), que é subsidiária integral da Eletrobrás, representou benefício à União. Isso porque a participação direta e indireta da União no capital social era de 46%, no caso da Petrobras, e de 67,2%, no caso da Eletrobrás, em dezembro de 2014¹⁵. Nesse sentido, o ganho que a União obteve como acionista da Eletrobrás teria superado a perda que sofreu como acionista da Petrobras.

25. De acordo com a área técnica, o benefício à União decorreria do fato de *"não precisar transferir imediatamente recursos para os Fundos Setoriais com o fim de que pudessem quitar sua dívida com a Amazonas Energia, assim permitindo que esta sociedade também adimplisse suas dívidas e não tivesse o fornecimento de gás interrompido por exceção de contrato não cumprido"*.

26. Nesse tocante, a SEP reporta-se à Portaria Ministerial nº 652, de 10.12.2014, que dispôs sobre a repactuação da dívida dos Fundos Setoriais com seus credores, entre os quais a Amazonas Energia, com prazo de pagamento de até dez anos e atualização do saldo devedor pela taxa SELIC. No entender da SEP, portanto, a União não seria obrigada a pagar imediatamente esta dívida, o que manteria hígido o sistema de distribuição de energia elétrica na região norte, justamente porque a Petrobras viria a aceitar a novação dos débitos das sociedades do Sistema Eletrobrás nas mesmas condições.

27. Pelo exposto acima, a SEP concluiu que a União Federal deve ser responsabilizada, na qualidade de acionista controladora da Petrobras, por descumprir o art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404, de 1976¹⁶, ao impor à companhia custos de subsidiar a geração de energia elétrica, por meio da omissão diante da reiterada inadimplência da Amazonas Energia e da posterior novação da dívida resultante dessa inadimplência, em termos desvantajosos para a Companhia, em dezembro de 2014.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

28. Examinada a peça acusatória, a PFE entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/08¹⁷.

V. DA DEFESA

29. A União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGNF, apresentou defesa tempestivamente, acostada às fls. 271 a 286.

30. De início, a Acusada destaca que, em suma, imputa-se à União uma ingerência indevida na repactuação de dívida realizada entre a Amazonas Energia e a Petrobras, que teria redundado em termos desvantajosos a esta última e, conseqüentemente, abuso de poder de controle decorrente da violação do art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 1976.

31. Observa que, de acordo com a Acusação, os termos desvantajosos consubstanciam-se porquanto a nova dívida — a ser paga em parcelas durante dez anos e remunerada pela taxa SELIC — possuiria valor presente líquido inferior à dívida originária, o que seria benéfico para a Amazonas Energia e prejudicial à

credora Petrobras. Portanto, deste abuso de poder, a União teria se beneficiado duplamente, tendo em vista que teria havido, pelos termos desvantajosos da repactuação, uma transferência de “valor” entre sua controlada direta (Petrobras) para a sua controlada indireta (Amazonas Energia), bem como um benefício pelo fato de não precisar transferir imediatamente recursos para os Fundos Setoriais (CDE) que seriam utilizados para o pagamento da dívida originária.

32. Alega a Acusação que, ao orientar esta repactuação, a União estaria impondo à Petrobras um ônus de subsidiar a geração de energia elétrica, o qual não se insere no bojo do seu objeto social, de modo que estariam sendo esgarçados os fins que justificaram a criação da companhia. Por fim, pesaria sobre a União, como acionista controladora da Petrobras, a acusação de ter se omitido, antes mesmo da referida repactuação, diante da reiterada inadimplência da Amazonas Energia perante a Petrobras, especificamente entre fevereiro de 2013 e novembro de 2014.

33. Segundo a União, portanto, a Acusação se utiliza de três premissas fáticas para individualizar a sua conduta abusiva, a saber:

- a) Que houve um prejuízo à Petrobras na repactuação da dívida com a Amazonas Energia;
- b) Que a aludida repactuação e o consequente prejuízo ocorreram com a orientação/participação direta da União; e
- c) Que a União poderia ter agido para evitar a inadimplência da Amazonas Energia perante a Petrobras e, consequentemente, a necessidade de uma renegociação desvantajosa.

34. Entretanto, a União alega que as premissas que embasaram a Acusação são equivocadas, pelas razões adiante expostas:

- a) A responsabilidade da União pelo exercício abusivo do poder de controle é sustentada por duas premissas que sequer foram minimamente comprovadas nos autos, quais sejam: que houve envolvimento direto da União, acionista controladora, na repactuação da dívida; e que a repactuação se deu em termos desvantajosos à Petrobras. Inexiste até mesmo indícios probatórios ou início de provas que pudessem incutir a ideia de veracidade das premissas apontadas, em suma, de justa causa para início do PAS;
- b) A imputação de exercício abusivo do controle pressupõe um envolvimento efetivo da União na condução da repactuação supostamente desvantajosa, o que não ocorreu no caso concreto. Toda a operação e suas tratativas teriam sido tomadas pela administração (Conselho de Administração e Diretoria) das companhias envolvidas, sem que a União, acionista controladora, delas participasse efetivamente;
- c) Caso diante de uma decisão assemblear, na qual a participação da União seria direta e efetiva, poder-se-ia cogitar potencial conflito de interesses na assinatura da repactuação (contrato entre partes relacionadas), devendo a mesma se abster de votar. Todavia, cuida-se no caso concreto de um ato de gestão celebrado pela administração de duas companhias independentes, no qual, até que se prove em contrário, não houve participação direta da controladora;
- d) Não prospera a simples alegação de que a Petrobras reconheceu a participação de representantes dos Ministérios da Fazenda e de Minas e

Energia na negociação, tendo em vista que não houve envolvimento com a conveniência e oportunidade da repactuação, tampouco com seus termos. O envolvimento se deu apenas no que diz respeito à garantia da operação, a qual, por partir da União, deveria contar com a participação do Ministério da Fazenda. Ademais, a participação do Ministério de Minas e Energia se impunha pelo fato da possível contragarantia envolver recursos da CDE;

- e) A SEP sequer *"carreou o contrato que lastreia a dívida originária, tampouco se esforçou para analisar comparativamente todos os riscos e chances de êxito para o seu recebimento. Pecou, neste diapasão, por não confrontar os dois instrumentos de dívida no afã de se alcançar conclusões seguras."*. Somente se pode afirmar que a repactuação é pior, ou melhor, após uma análise sobre o contrato originário, o que, equivocadamente, não fora feito pela acusação;
- f) Ainda no que concerne aos vícios do Termo de Acusação, a SEP, embora aponte genericamente o abuso de controle por parte da União, não aponta em qual modalidade ou conduta de poder abusivo (art. 117 da Lei nº 6.404, de 1976) ela teria incorrido;
- g) A SEP sequer menciona o aludido dispositivo, que trata de responsabilidade do controlador por abuso de poder, o que acaba dificultando/impossibilitando a defesa e, por conseguinte, violando os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, a ensejar a nulidade da Acusação;
- h) Clama para que a Acusação seja declarada nula, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ou, assim não entendendo o Colegiado, que seja extinta sem análise de mérito, por não estar acompanhada de elementos probatórios que preencham uma das condições da ação (a justa causa).

35. Na análise do mérito, a União expôs, primeiramente, as razões pelas quais a atuação da Petrobras teria ocorrido dentro dos limites de seu objeto social. Sobre isso, a União afirmou que a repactuação da dívida originária do contrato de fornecimento de gás para geração de energia pela Amazonas Energia está inclusa, inegavelmente, nos fins que justificam a criação da Companhia e, consequentemente, nos limites do seu objeto social, conforme o artigo 26 da Lei nº 10.438, de 2002¹⁸ e o artigo 3º do Estatuto Social da Petrobras¹⁹. A União alegou ainda que incube ao Poder Legislativo, e não à CVM, a definição do interesse coletivo que deve ser perseguido por uma empresa estatal, nos termos do art. 173 da Constituição Federal. Desse modo, tal acusação deveria ser julgada improcedente no entendimento da União.

36. Ainda no mérito, a União alegou que a conclusão do Termo de Acusação, no sentido de que a repactuação da dívida entre a Amazonas Energia e a Petrobras fora desvantajosa para o interesse desta última, baseia-se em uma visão demasiadamente estreita da operação, na medida em que analisa tão somente as circunstâncias que favorecem a tese acusatória, sem se preocupar com todo o contexto fático, jurídico e econômico da sua concretização. Nesse sentido, três questionamentos deveriam ser respondidos:

- (i) Será realmente que a dívida originária tinha liquidez e certeza quando da repactuação?
- (ii) Será que as chances de êxito em uma cobrança judicial eram tão robustas ao ponto de ser desvantajosa a repactuação?

- (iii) A repactuação ocorreu por um valor líquido inferior a dívida originária e, consequentemente, de forma desvantajosa?

37. Quanto aos dois primeiros questionamentos, a União destacou que, no extrato da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 08.8.2014²⁰, o presidente da Petrobras Distribuidora alertou que o fornecimento de gás à Amazonas Energia fora feito, ao longo do tempo, sem um contrato formal. Ademais, a própria área técnica da Petrobras teria dúvidas a respeito da liquidez e certeza da dívida originária, dando a entender que a cobrança, possivelmente, dar-se-ia por meio de uma ação ordinária de conhecimento, conforme descrito às fls. 58 e 59 dos autos, tendo em vista que somente em 2013 fora realizada licitação para o fornecimento de gás à Amazonas Energia. Portanto, antes da referida licitação, a Petrobras só possuía em face da Amazonas Energia meras faturas de cobrança, o que, para a União, inviabilizaria uma possível ação de execução judicial, restando somente a possibilidade de manejo de uma ação ordinária de conhecimento ou uma ação monitória. E, com a judicialização da questão, a Amazonas Energia poderia discutir amplamente o mérito da dívida, assumindo a Petrobras o risco de não receber de imediato qualquer quantia.

38. Sobre isso, a União ainda apontou que a Amazonas Energia é a principal prestadora regional do serviço público de distribuição e, por isso, dificilmente o Poder Judiciário autorizaria o corte do fornecimento de gás a fim de compelir a empresa a adimplir sua dívida. Além disso, a Amazonas Energia não possui bens susceptíveis de penhora, na medida em que todos os bens afetados à atividade, de acordo com pacífica jurisprudência, não seriam passíveis de constrição judicial.

39. Portanto, a União defende que foi justamente neste cenário de risco e insegurança que a administração da Petrobras (Conselho de Administração e Diretoria), sem qualquer orientação da União, optou por repactuar a dívida.

40. Quanto ao terceiro questionamento acima, a União inicialmente observou que a repactuação resultou em uma confissão no montante de R\$3.257.365.513,24 (três bilhões, duzentos e cinquenta e sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e vinte centavos), que perfaz o valor da dívida originária corrigida pela Taxa SELIC e com multa de mora de 2% até o dia 05.12.2014, a ser paga em 120 parcelas e remunerada também pela SELIC. Destacou que a parte da dívida originária que possuía lastro contratual contava justamente com os consectários previstos na repactuação (Taxa SELIC e multa de mora de 2%), de sorte que, caso a opção fosse cobrar o valor originário imediatamente, a forma de correção e atualização da dívida seria a mesma.

41. Nesse sentido, a União argui ser no mínimo temerário afirmar que a repactuação não fora vantajosa para a Petrobras, do ponto de vista financeiro (custo/benefício). Primeiro, porque a repactuação respeitou todas as cláusulas contratuais anteriores e originárias (referentes à parte da dívida originária que tinha lastro contratual) e permitiu que a Petrobras começasse a receber seus créditos imediatamente, ainda que em parcelas, reforçando seu caixa. Segundo, porque após a repactuação passou-se a contar com título executivo extrajudicial apto a amparar uma ação autônoma de execução em caso de inadimplemento, possibilitando, em princípio, a satisfação do credor de forma mais célere do que numa ação de conhecimento, tal como uma ação ordinária de cobrança.

42. No entender da União, não prospera a alegação de que a taxa pactuada deveria ser superior à taxa SELIC, pois nem mesmo a parte da dívida originária (que possuía lastro contratual) contava com a previsão de remuneração pela SELIC. Além disso, caso se optasse pelo ajuizamento da ação, ao invés da repactuação, seria a Taxa SELIC que remuneraria o valor cobrado, de sorte que não há qualquer prejuízo na sua escolha.

43. Quanto à garantia ofertada, a União concluiu que houve uma substancial melhora do crédito. Originariamente, o que existia era tão somente a garantia pessoal prestada pela Eletrobrás, porém, junto à confissão de dívida, foi celebrado Contrato de Penhor em Garantia entre a Petrobras e a Amazonas Energia, de parte dos créditos que esta última detém junto à CDE. Essa última garantia, por ser real, teria aptidão de melhorar a qualidade do crédito.

44. Pelos argumentos acima elencados, a União defende que os termos da repactuação foram vantajosos para a Petrobras, devendo a Acusação ser julgada improcedente.

45. Especificamente quanto à alegação da SEP de que a União teria se omitido diante do inadimplemento da Amazonas Energia para com a Petrobras, a Acusada alega que há que se considerar que as referidas companhias são pessoas jurídicas de direito privado autônomas, que possuem administração tecnicamente independente e com autonomia de gestão, não competindo à União, ainda que detenha o controle acionário de ambas, intrometer-se em contratos de direito privado celebrado entre elas. Assim, as medidas necessárias ao cumprimento de quaisquer contratos entre as duas companhias devem ser conduzidas por seus administradores, os quais têm o dever de atuar com diligência e buscar sempre lograr os fins e os interesses das companhias, satisfeitas as exigências do bem público e da função social das empresas (artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404, de 1976).

46. Segundo a Acusada, a conveniência e oportunidade, bem como a análise dos riscos, referentes às medidas tomadas para cobrar os valores devidos pela Amazonas Energia à Petrobras, são de inteira responsabilidade dos administradores desta última, na medida em que se trata de matéria eminentemente de gestão. Vale dizer, incumbia à Diretoria e ao Conselho de Administração da Petrobras, nos termos dos artigos 138 e 139 da Lei 6.404, de 1976²¹, a decisão de demandar ou não à devedora, assim como todos os consectários desta escolha. E assim fez a administração da Petrobras, como se verifica das atas anexas aos autos.

47. A União argui que não houve nenhuma espécie de omissão por parte do controlador, pois, como visto, não caberia a ele tomar medidas para o recebimento imediato do crédito, podendo até mesmo ficar caracterizado um conflito objetivo de interesses.

48. Por fim, a União refutou a acusação de que teria participado diretamente da repactuação entre a Petrobras e a Amazonas Energia, orientando de forma a privilegiar a primeira companhia em detrimento da segunda. Defende que, mesmo se houvesse um prejuízo para a Petrobras, o mesmo não poderia ser imputado à União, ante a inexistência de nexo causal entre a sua conduta como controladora e a repactuação.

49. A União defende que, muito embora a Acusação não tenha indicado em qual modalidade de abuso de controle ela teria incorrido, as únicas que potencialmente poderiam amparar a tese da SEP são aquelas previstas nas alíneas "a" e "f" do §1º do art. 117 da lei nº 6.404, de 1976²². Todavia, ambas as espécies somente se concretizam diante de uma orientação clara e inequívoca por parte do

controlador, seja por meio de deliberação assemblear, seja mediante influência ou pressão externa contundente, o que não ocorrera no caso concreto.

50. A União observa que o único envolvimento que se possa atribuir a ela se restringe à oferta da garantia e à análise da suficiência da contragarantia à repactuação, sendo esta última uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 40 da LC nº 101, de 2000), vez que, ao fornecer garantia à operação celebrada, deve a União, como garantidora, analisar os riscos da dívida garantida e exigir contragarantia. O fato de a União, ainda que controladora das companhias envolvidas, prestar garantia à operação, não faz dela participante direta na confissão de dívida garantida, objeto da Acusação.

51. A Acusada entende que incumbe aos administradores explicar a conveniência e oportunidade da repactuação, bem como suas cláusulas, não restando quaisquer responsabilidades sobre a controladora União.

52. Assim, convencida de que houve violação do contraditório e da ampla defesa, a União pede que o processo seja declarado nulo. Caso o Colegiado entenda o contrário, postula que o pedido da SEP seja julgado extinto sem análise do mérito, tendo em vista a ausência de justa causa. Porém, se o Colegiado entender que a análise do mérito é necessária, pede que o processo seja julgado improcedente.

VI. DO TERMO DE COMPROMISSO

53. Com fulcro no art. 11, §5º, da Lei 6.385, de 1976, e no art. 7º da Deliberação CVM 390, de 2001, a União apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso, posteriormente retirada diante da manifestação adversa da PFE relativa ao cumprimento dos requisitos legais necessários à celebração do ajuste²³ (fls. 311/331).

VII. DA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

54. Em 03.01.2017, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, em reunião do Colegiado realizada nesta data, nos termos do art. 9ª da Deliberação CVM nº 558/08 (fls. 377).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR

¹ Informações prestadas pelo DRI da Petrobras às fls. 57/62 e também extraídas do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" às fls. 20/24.

² "Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. (...) §2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação".

³ Fls. 58.

⁴ A Amazonas Energia vale-se dos subsídios provenientes dos Fundos Setoriais para arcar com os custos de aquisição de gás natural para geração de energia que distribui nos termos da Lei nº 12.111, de 2009. A existência dessa dívida é reconhecida pela Portaria Interministerial nº 652, de 2014, dos Ministérios da Fazenda e das Minas e Energia.

⁵ Na nota explicativa nº 15.5 das demonstrações financeiras de 31.12.2014, a administração da Eletrobrás reconhece que a Amazonas Energia é dependente do seu suporte financeiro.

⁶ A dívida originária era R\$2,94 bilhões (fls. 20v).

⁷ A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é destinada à promoção do desenvolvimento energético dos estados, a projetos de universalização dos serviços de energia elétrica, ao programa de subvenção

aos consumidores de baixa renda e à expansão da malha de gás natural para o atendimento dos estados que ainda não possuem rede canalizada. Criada em 26 de abril de 2002 pela Lei nº 10.438, a CDE é gerida pela Eletrobras, cumprindo programação determinada pelo Ministério de Minas e Energia (Fonte: <http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?Team=%7BAAF6D338%2D7190%2D4968%2D8F49%2DC2303AC2F7C7%7D>).

⁸ Conforme autorizado pelo Decreto nº 8.370, de 10.10.2014.

⁹ "Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (...) II - O documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível;"

¹⁰ "Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação."

¹¹ "Art. 9º - Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, analisando objetivamente a observância dos requisitos do art. 6º e o cumprimento do art. 11."

¹² O risco de crédito das sociedades do Sistema Eletrobrás, que inclui a Amazonas Energia, é tão significativo que justificou, em 2014, o reconhecimento pela Companhia de R\$ 4,5 bilhões, incluindo saldos a vencer das novas dívidas, que possuem garantia pessoal da Eletrobrás, como perdas em créditos de liquidação duvidosa.

¹³ "Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

¹⁴ Recurso Especial nº 727.842.

¹⁵ Considerando a participação indireta por meio de outras entidades ligadas à União.

¹⁶ Art. 116. *Parágrafo único.* O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

¹⁷ Parecer nº 00097/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, às fls. 147/158.

¹⁸ "Art. 26. Fica a *Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, sociedade de economia mista, criada pela Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953*, autorizada a incluir no seu objeto social as atividades vinculadas à energia."

¹⁹ "Art. 3º- A Companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins".

²⁰ Folhas 71 e 72.

²¹ "Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

§1º - O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores.

§2º - As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de administração.

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto."

²² "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

§1º - São modalidades de exercício abusivo de poder:

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;

(...)

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;"

²³ Parecer nº 0005/2016/GJU – 2/PFE-CVM/PGF/AGU (FLS. 323/329).

¹ Art. 116. *Parágrafo único.* O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

¹ A existência dessa dívida é reconhecida pela Portaria Interministerial nº 652, de 2014, dos Ministérios da Fazenda e das Minas e Energia.

¹ Na nota explicativa nº 15.5 das demonstrações financeiras de 31.12.2014, a administração da Eletrobrás reconhece que a Amazonas Energia é dependente do seu suporte financeiro.

¹ A dívida originária era R\$2,94 bilhões (fls. 20v).

¹ O risco de crédito das sociedades do Sistema Eletrobras, que inclui a Amazonas Energia,

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/10677

Acusada: União Federal

Assunto: Apurar a responsabilidade da União Federal, na qualidade de acionista controladora da Petróleo Brasileiro S.A., por infração ao artigo 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face da União Federal ("**União**"), na qualidade de acionista controladora da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("**Petrobras**" ou "**Companhia**"), para apurar sua omissão diante da reiterada inadimplência da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. ("**Amazonas Energia**") e da posterior novação da dívida resultante dessa inadimplência em termos desvantajosos para a Petrobras, impondo à Companhia custos a fim de subsidiar a geração de energia elétrica na região norte do país, em violação ao art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404, de 1976¹.

2. Como visto no relatório, em junho de 2006 a Amazonas Energia contratou com a Petrobras o fornecimento de gás natural para a geração de energia elétrica, contudo, a partir de 2011, ela deixou de adimplir suas obrigações com a contratada sem que esta tenha interrompido o fornecimento de gás (verso da fl. 20).

3. Segundo consta dos autos, a Amazonas Energia deixou de adimplir suas obrigações com a Petrobras porque os Fundos Setoriais não realizaram integralmente as transferências com as quais estavam comprometidos, com o fim de subsidiar a geração de energia elétrica na região norte², e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("**Eletrobras**") não se dispôs a investir recursos na sua subsidiária integral que fossem suficientes para compensar a indisponibilidade orçamentária dos Fundos Setoriais³.

4. Em 31.12.2014, a Petrobras e a Amazonas Energia celebraram "Instrumento Particular de Confissão de Dívida", no qual a contratante reconheceu dever à Petrobras a quantia de R\$3,26 bilhões, em valores atualizados até 05.12.2014⁴, referentes ao fornecimento de gás entre fevereiro de 2013 e novembro de 2014 (fls. 20/25).

5. Nos termos do referido acordo, a Amazonas Energia comprometeu-se a liquidar a dívida junto à Petrobras em 120 prestações mensais e consecutivas (vencendo a primeira em 20.2.2015), atualizadas pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais ("**SELIC**"), sendo ainda estabelecido que a União prestaria "garantia fidejussória irrevogável e irretroatável". Tal garantia era vinculada à contragarantia que deveria ser outorgada à União pela Eletrobras e pela Amazonas Energia até 15.2.2015, caso contrário, passaria a Eletrobras à condição de fiadora e devedora solidária da dívida (cláusulas segunda e quarta do acordo).

6. Diante destes fatos, a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") entendeu que a novação de dívida seria financeiramente

desvantajosa para a Petrobras, pois a taxa de desconto da dívida da Amazonas Energia deveria necessariamente ter sido superior à SELIC, dado que o risco de crédito da Amazonas Energia e de sua controladora Eletrobras era superior ao da União⁵. Com isso, a nova dívida a ser paga em 120 meses e remunerada pela taxa SELIC possuiria valor presente líquido inferior a R\$3,26 bilhões, dívida esta que no sentir da Acusação seria líquida e exigível em dezembro de 2014.

7. No entender da SEP, a Petrobras teria transferido riqueza para a Amazonas Energia consistente na diferença entre os R\$ 3,26 bilhões e o menor valor presente líquido da nova dívida pactuada, arcando assim efetivamente com os custos do subsídio ao serviço de distribuição de energia nos sistemas isolados, o que teria se dado em favor da acionista controladora, na medida em que teria havido transferência de riqueza de uma controlada direta (Petrobras) para uma controlada indireta (Amazonas Energia), na qual a União detinha maior participação acionária⁶.

8. Outro benefício apontado pela Acusação à controladora decorreria do fato de a União não ter precisado aportar, em 2014, grande volume de recursos nos Fundos Setoriais do setor elétrico brasileiro, que deveriam ser utilizados para o pagamento da dívida originária, uma vez que a Petrobras viria a aceitar a novação da dívida com a Amazonas Energia nas mesmas condições da repactuação da dívida desses Fundos Setoriais com as sociedades do Sistema Eletrobras, conforme Portaria dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda nº 652, de 10.12.2014.

9. A Defesa, por sua vez, aduz que há de se considerar que as referidas companhias são pessoas jurídicas de direito privado autônomas, que possuem administração tecnicamente independente e com autonomia de gestão, não competindo à União, ainda que detenha o controle acionário de ambas, intrometer-se em contratos de direito privado celebrado entre elas. Assim, as medidas necessárias ao cumprimento de quaisquer contratos entre as duas companhias devem ser conduzidas por seus administradores, os quais têm o dever de atuar com diligência e buscar sempre lograr os fins e os interesses das companhias, satisfeitas as exigências do bem público e da função social das empresas (artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404, de 1976).

10. A Defesa também refuta a acusação de que a União teria participado diretamente da repactuação entre a Petrobras e a Amazonas Energia, orientando de forma a privilegiar a primeira companhia em detrimento da segunda. Observa que o único envolvimento que se poderia atribuir à União restringe-se à oferta da garantia e à análise da suficiência da contragarantia à repactuação, sendo esta última uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 40 da LC nº 101, de 2000), vez que, ao fornecer garantia à operação celebrada, deveria a União, como garantidora, analisar os riscos da dívida garantida e exigir contragarantia. O fato de a União, ainda que controladora das companhias envolvidas, prestar garantia à operação, não faria dela participante direta na confissão de dívida objeto da Acusação.

11. Alega ser no mínimo temerário afirmar que a repactuação não seria vantajosa para a Petrobras, pois a repactuação teria respeitado todas as cláusulas contratuais anteriores e originárias (referentes à parte da dívida originária que tinha lastro contratual) e permitido que a Petrobras começasse a receber seus créditos imediatamente, ainda que em parcelas, reforçando seu caixa. Além disso, após a repactuação a Petrobras passaria a contar com título executivo extrajudicial apto a amparar uma ação autônoma de execução em caso de inadimplemento, possibilitando, em princípio, a satisfação do credor de forma mais célere do que numa ação de conhecimento, tal como uma ação ordinária de cobrança.

12. No entender da Defesa, tampouco prospera a alegação de que a taxa pactuada deveria ser superior à taxa SELIC, pois nem mesmo a parte da dívida originária contava com a previsão de remuneração pela SELIC. Além disso, caso se optasse pelo ajuizamento da ação, ao invés da repactuação, seria a taxa SELIC que remuneraria o valor cobrado, de sorte que não há qualquer prejuízo na sua escolha.

I – Da Preliminar

13. Trazidos os principais elementos do presente processo, cabe examinar, preliminarmente, o argumento da Defesa de que não estariam presentes os requisitos necessários para a configuração da modalidade omissiva de abuso de poder de controle, na medida em que a Acusação não apontou qual modalidade de conduta abusiva existente no art. 117 da Lei nº 6.404, de 1976, teria sido cometida pela União, o que acabou dificultando a elaboração da Defesa e, por consequência, violando os direitos da ampla defesa e do contraditório, a ensejar a nulidade da Acusação.

14. Tal argumento não pode prosperar porque o Colegiado⁷ da CVM já firmou entendimento de que é possível responsabilizar o acionista controlador por condutas omissivas em função dos deveres estabelecidos no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 1976, que impõe ao controlador o dever de *"usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender."*

15. Da leitura do artigo antes transcrito depreende-se que, caso o acionista controlador não utilize seu poder para realizar o objeto social da companhia, fazer cumprir a sua função social ou atender direitos e interesses dos demais acionistas, ele viola dever de agir imposto por lei, a caracterizar infração por omissão ao mencionado dispositivo.

16. E foi justamente com base neste entendimento que foi construída a tese acusatória no sentido de que, diante da reiterada inadimplência da Amazonas Energia perante a Petrobras e da posterior repactuação da dívida, a União teria deixado de atender aos interesses dos demais acionistas da Petrobras, em violação ao parágrafo único do art. 116 da Lei nº 6.404, de 1976.

17. Por outro lado, não se pode deixar de comentar que, embora o Termo de Acusação tenha se limitado ao descumprimento do art. 116, há trechos da peça acusatória que se referem a aspectos de modalidade de abuso de poder de controle descrito no art. 117, §1º, "f", da Lei nº 6.404, de 1976, o que muito provavelmente deu origem ao presente questionamento. Todavia, tais menções estão intimamente ligadas com a análise de mérito da Acusação, de forma que elas serão examinadas no decorrer deste voto.

18. Por tais razões, afasta-se tal preliminar.

19. Vale destacar também em sede preliminar que, originalmente, a SEP havia imputado à União a violação ao art. 238 da Lei nº 6.404, de 1976⁸, porém excluiu tal acusação ao acolher sugestão contida no parecer da Procuradoria Federal Especializada – PFE, emitido por ocasião da análise da peça acusatória, em atendimento ao disposto no art. 9º da Deliberação CVM nº 538, de 2008. Não obstante, a SEP optou por registrar na versão final do Termo de Acusação o seu entendimento inicial acerca da matéria, sob o argumento de que poderia o

Colegiado, caso julgasse conveniente, considerá-lo em sua decisão⁹. Nesse sentido, consignou que o uso dado à Petrobras frente aos objetivos que justificam a sua criação seria no mínimo controverso, ainda que tal controvérsia não tenha alcançado a imputação ao final atribuída à União.

20. Em que pese a intenção da área técnica, não é possível análise pelo Colegiado, em sede de julgamento, de conduta que não fora imputada pela Acusação, pois o regime regulatório estabelecido pela Deliberação CVM nº 538, de 2008, segregou as funções investigativa e acusatória da função julgadora. A mencionada deliberação atribuiu às superintendências autonomia para a condução do procedimento apuratório e a formulação da acusação, ao passo que reservou ao Colegiado o julgamento dos processos sancionadores.

21. Como a SEP decidiu suprimir do Termo de Acusação eventual acusação de infração ao art. 238 da Lei nº 6.404, de 1976, anuindo com o entendimento manifestado pela PFE, não cabe ao Colegiado, em respeito ao regime regulatório em vigor, acrescentar em sede de julgamento imputação ao Acusado além daquela que consta da peça acusatória.

22. Por tal razão, restou prejudicada eventual admissão e apreciação, pelo Colegiado, do entendimento inicial da SEP sobre a matéria.

II – Do Mérito

23. Como visto, a controvérsia do presente processo consiste em examinar se a União, na qualidade de acionista controladora da Petrobras, quedou-se inerte em face do inadimplemento da Amazonas Energia e da repactuação da dívida havida entre as suas controladas, de forma a beneficiar a Amazonas Energia em detrimento da Petrobras, logrando com isso vantagem indevida.

24. Antes, porém, de examinar a conduta da União no presente caso, é importante destacar que a Lei nº 6.404, de 1976, atribuiu à pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista os mesmos deveres e responsabilidades conferidos ao controlador privado (artigos 116 e 117), ressaltando, contudo, que ele poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação, conforme prevê o art. 238 da mesma lei.

25. O Colegiado da CVM enfrentou tal questão recentemente ao examinar o PAS CVM nº RJ2013/6635, julgado em 26.05.2015, quando condenou a União Federal por votar pela renovação das concessões de distribuição e transmissão de energia elétrica de companhias controladas pela Eletrobras, em infração ao disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/76, uma vez que tal decisão envolvia interesses externos da União e a beneficiária de forma particular, colocando-a em situação de conflito.

26. Como bem consignado no voto da Diretora-Relatora Luciana Dias, muito embora o acionista controlador da sociedade de economia mista possa tomar decisões alinhadas ao interesse público que justificou a criação da sociedade (art. 238), ele está obrigado a observar todas as demais regras da Lei nº 6.404, de 1976, inclusive as que limitam o seu próprio poder (art. 235 e art. 115, §1º, e artigos 116 e 117).

27. Assim, a atuação do acionista controlador das sociedades de economia mista tem recebido olhar atento por parte da CVM, pois, diante dos fatos notórios ocorridos, somente a percepção clara de que há limites para atuação da pessoa que controla a companhia de economia mista poderá recuperar a confiança dos agentes

de mercados nestas companhias, que são, sabidamente, de grande importância para o desenvolvimento econômico brasileiro.

28. Neste sentido, merece destaque o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, recentemente editado, que, para as sociedades de economia mista, recomenda como boa prática de governança a identificação clara e precisa do interesse público que justificou a criação da sociedade, em capítulo específico, bem como atuação proativa do Conselho de Administração no monitoramento das atividades da companhia e no estabelecimento de políticas, mecanismos e controles internos ***“para apuração dos eventuais custos do atendimento do interesse público e eventual ressarcimento da companhia ou dos demais acionistas e investidores pelo acionista controlador”***. A incorporação do referido código às normas da CVM está em audiência pública, nos termos do Edital de Audiência Pública SDM Nº 10/16.

29. Na mesma linha, foi criado o Estatuto das Empresas Estatais (Lei nº 13.303, de 2016), que, em seu art. 6º, determina que a sociedade de economia mista *“deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção”*, e, em seu art. 14, estabelece que o acionista controlador da sociedade de economia mista *“deverá preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções”*.

30. Além disso, o referido estatuto também proibiu a indicação para o Conselho de Administração e Diretoria representantes do órgão regulador ao qual a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de dirigente estatutário de partido político, de titular de mandato no Poder Legislativo, dentre outras vedações, buscando afastar ao máximo eventual influência política nos órgãos decisórios das companhias (art.17, §2º).

31. Como se vê, as atenções estão voltadas para as sociedades estatais e seus correspondentes acionistas controladores que, repita-se, devem orientar as atividades sociais em harmonia com os interesses dos demais acionistas, não podendo pautar sua atuação em desrespeito ao capital privado, sob pena de responsabilização.

32. Feitos estes comentários e retornando ao caso concreto, impõe-se afirmar, desde logo, que a Acusação não conseguiu reunir elementos suficientemente aptos a comprovar a responsabilidade da União no presente processo.

33. A Lei 6.404, de 1976, atribuiu distintas responsabilidades para administradores e controladores de uma companhia, no que se refere especificamente à realização de operações entre partes relacionadas, matéria objeto deste processo.

34. O art. 245 da Lei das S/A estabeleceu que *“os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo”*. No tocante à responsabilidade dos acionistas controladores, a referida lei reservou a alínea “f” do §1º do art. 117 para tratar do tema, ao dispor que o acionista controlador responde pelos danos causados por contratar com a companhia, diretamente ou através de

outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas.

35. O Colegiado da CVM delimitou os contornos destas responsabilidades no recente julgamento do PAS CVM nº RJ2012/11199, de 22.3.2016, cujos trechos do voto proferido pelo Diretor-Relator Pablo Renteria estão transcritos a seguir:

"14. Neste tocante, o que se verifica é que a Lei nº 6.404/1976 submeteu administradores e controladores a responsabilidades distintas no que diz respeito à realização de operações entre a companhia e sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.

15. De uma parte, em atenção ao disposto no art. 245, cumpre aos administradores zelar para que essas transações sejam equitativas. Ou seja, devem agir com especial diligência, adotando, durante o processo decisório, medidas aptas a resguardar os interesses da companhia frente ao risco de favorecimento do controlador.

16. Este Colegiado já esclareceu, a propósito, que "as operações entre controlador e controlada colocam um ônus muito maior sobre os administradores envolvidos, (...). Todo o cuidado e diligência que se exige dos administradores em condições normais deve ser redobrado em negócios entre partes relacionadas (...)"¹⁰.

17. Dada a natureza eminentemente procedimental desse dever, a conduta dos administradores se presta perfeitamente ao tipo de escrutínio levado a cabo pela SEP nos autos deste processo, que, como visto, centra-se no modo de condução da negociação que antecedeu à contratação. Incumbe então à CVM avaliar as medidas adotadas pelos administradores para assegurar o equilíbrio da operação, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto – em especial a relevância do negócio para a companhia e o tempo de que dispunham os administradores para tomar a decisão.

18. De outra parte, em consonância com o disposto no art. 117, §1º, alínea "f", o controlador não pode abusar de sua autoridade sobre a administração para contratar com a companhia em condições não equitativas. Extrai-se do texto normativo que a análise da CVM, neste caso, há de ser substancial, configurando-se o abuso apenas mediante a demonstração de que a transação foi lesiva para a companhia¹¹. Ainda que o processo de negociação que levou à contratação não tenha sido conduzido a contento, o controlador deve ser responsabilizado apenas se restar comprovado que os termos do contrato o favoreceram em detrimento da companhia.

19. A isso se poderia objetar que seria mais justo tratar o controlador do mesmo modo que os administradores, tendo em vista a influência que ele é capaz de exercer na condução dos negócios da companhia. Nessa direção, poderia aventar-se a possibilidade de responsabilizá-lo por eventuais falhas verificadas no processo de negociação, com base no parágrafo único do art. 116, sob a alegação de que se trata de modalidade de abuso diversa daquela prevista no art. 117, §1º, alínea "f".

20. Tal posição, contudo, não me parece correta, uma vez que confunde perigosamente as funções desempenhadas pelos administradores com aquelas do controlador. Isto porque, no regime jurídico adotado pela Lei nº 6.404/1976, compete à administração, e em particular à diretoria, conduzir o processo de negociação que precede a contratação, em nome da companhia, com terceiros. E por isso mesmo, caso sejam identificadas falhas nesse processo, cumpre aos administradores, nos limites de suas atribuições, responder pelas consequências daí decorrentes.

21. Ademais, a responsabilização do controlador teria o efeito indesejável de incentivá-lo a intervir nas negociações realizadas pela companhia, pois, sendo responsável, é mesmo de se esperar que tenha participação ativa nesse processo.

22. Parece-me, portanto, que se estaria dessa maneira caminhando na contramão das melhores práticas de mercado, estimulando-se a interferência do controlador na contratação com sociedade integrante do mesmo grupo econômico, quando o mais adequado, do ponto de vista da governança, é que se abstenha de qualquer ingerência, permitindo que a administração conduza a operação com plena independência.

23. É em vista disso que me parece especialmente importante que a CVM delimite, com clareza, os deveres e responsabilidades que tocam ao controlador, de modo a evidenciar que a condução do processo de negociação compete aos administradores, que não podem eximir-se

do dever de zelar pela equidade da operação realizada com sociedade do mesmo grupo econômico, nem mesmo sob a alegação de que agiram sob a direção do controlador.”

36. Deste modo, compete à administração, e em particular à diretoria, conduzir o processo de negociação que precede a contratação, em nome da companhia, com terceiros (artigos 138 e 139), e, caso sejam identificadas falhas nesse processo, cumpre aos administradores, nos limites de suas atribuições, responder pelas consequências de seus atos comissivos ou omissivos em face de seus deveres estabelecidos nos artigos 153 a 157 da Lei nº 6.404, de 1976.

37. Como os administradores são os responsáveis diretos pela condução dos negócios de uma companhia, não se pode atribuir automaticamente responsabilidade ao acionista controlador quando os administradores violem os seus deveres, visto que as companhias possuem administração independente e com autonomia de gestão. Com efeito, tal caracterização depende da identificação do grau de influência do acionista controlador na administração da companhia ou no desfecho de determinado negócio, ou ainda do momento a partir do qual a não interferência do acionista controlador em relação a assunto relevante para a companhia é reprovável em face de seus deveres estabelecidos nos art. 116 e 117 da Lei nº 6.404, de 1976.

38. No que se refere a este último aspecto, deve-se admitir a dificuldade em se caracterizar precisamente o momento a partir do qual a omissão do acionista controlador é repreensível, pois, como já dito, cabe aos administradores à condução do dia-a-dia da companhia. A CVM já enfrentou essa questão no julgamento do PAS CVM nº RJ2012/1131, julgado em 26.5.2015, ao considerar irregular a atuação do Estado de São Paulo, na qualidade de acionista controlador da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“EMAE”), em relação a operações realizadas entre a EMAE e a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – Sabesp (“Sabesp”), outra companhia por ele controlada.

39. Segundo restou comprovado, o Estado de São Paulo deixou de atender os interesses dos demais acionistas da EMAE ao permanecer inerte durante vários anos em face da relação desvantajosa em que se encontrava a EMAE, devido à captação gratuita de águas pela Sabesp sem que houvesse qualquer compensação à EMAE pela retirada de águas, mesmo após ser instado pela administração da EMAE para resolver o impasse entre as companhias.

40. A primeira circunstância a enfraquecer a tese acusatória de que a União teria se omitido diante da inadimplência da Amazonas Energia diz respeito à atuação proativa da administração da Petrobras em resolver a pendência financeira com a sociedade sob controle comum.

41. Os documentos constantes dos autos revelam que os impactos da dívida da Amazonas Energia e o status de negociação já em trâmite com a devedora vinham sendo amplamente discutidos no âmbito da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Petrobras (fls. 63 a 86).

42. A partir desses documentos, infere-se que em março de 2014 já existia proposta de negociação da dívida da Eletrobras junto a Petrobras, com base em valor atualizado até 31.12.2013, para pagamento em 84 vezes e com atualização pela Taxa SELIC¹², conforme solicitação de aprovação constante do Documento Interno Petrobras (DIP) Finanças nº 65, de 7.3.2014. Observa-se que tais

condições muito se assemelham àquelas ao final acordadas entre as partes em dezembro de 2014.

43. Ressalta-se, ainda, o extrato da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 29.8.14, onde se consignou a solicitação de aprovação da avaliação do crédito do Sistema Eletrobras e das alternativas existentes para o tratamento da dívida junto à Petrobras¹³, bem como a ciência das proposições contidas no DIP Finanças nº 165, de 8.7.2014, dentre as quais a postergação, para 1º de agosto, da decisão de envio de Notificação Extrajudicial para a Amazonas Energia requerendo o reforço de garantia que pudesse ser negociada no mercado financeiro (monetizada) nos termos do Contrato celebrado entre a Petrobras e a Cigás. O assunto foi novamente pautado em reunião do Conselho Fiscal realizada em 26.9.2014, por meio do DIP Finanças nº 179, de 1.8.2014, referente às providências para cobrar os valores e evitar a prescrição do crédito.

44. No âmbito do Conselho de Administração, vale destacar a reunião realizada em 8.8.2014 (Ata às fls. 68/71), ocasião em que se registrou que a Diretoria da Petrobras não se sentia autorizada a determinar a paralisação do suprimento de gás natural, por mais que fosse justificado financeiramente ou comercialmente. Isso porque, naquele momento, a Petrobras respondia pelo suprimento de energia do Estado do Amazonas e qualquer descontinuidade nesse fornecimento poderia *"comprometer a segurança energética nacional"*.

45. Nessa reunião, o presidente da Petrobras Distribuidora S.A. ("Petrobras Distribuidora"), que participou como convidado, atualizou as informações relativas às tratativas de pagamento das dívidas vencidas do Sistema Eletrobras (R\$1.452 milhões), comunicando ainda o que se segue:

- a) O recebimento de carta da Eletrobrás em 31.7.2014, por meio da qual manifestou a impossibilidade, naquela data, de cumprir o pagamento de R\$452 milhões à vista, bem como o pagamento parcelado do saldo restante, posto que ainda estava aguardando o fechamento de empréstimo com o Governo;
- b) A remessa de carta à Eletrobras em 31.7.2014, informando que a Petrobras Distribuidora passaria a exigir pagamento antecipado pelos fornecimentos a partir de 1.8.2014;
- c) A Petrobras Distribuidora decidiu não cortar todos os fornecimentos à Amazonas Energia para não provocar o desabastecimento de energia elétrica na Amazônia, porém limitá-lo a um valor de R\$30 milhões; e
- d) Os fornecimentos ao Sistema Eletrobras na Amazônia vinham há longo tempo sendo feitos sem contrato formal, mas em 2013 a Petrobras venceu licitação para a continuidade dos fornecimentos, que seriam objeto de contrato já pronto para assinatura. Tal contrato conteria cláusula estabelecendo que a suspensão de fornecimento somente poderia ocorrer após três meses de inadimplência.

46. Restou ainda consignado na ata da reunião os seguintes esclarecimentos:

- a) Em 4.8.2014, a Diretoria Executiva da Petrobras decidiu enviar, em 11.8.2014, Notificação Extrajudicial para a Amazonas Energia e a Cigás, como devedoras principais, e para a Eletrobras, como fiadora, para: (i) pagamento integral dos valores inadimplidos com a Petrobras; ou (ii)

apresentação de nova proposta de parcelamento dos valores inadimplidos, desde que acompanhada de garantia monetizável no mercado financeiro, e aceita pela Petrobras; e (iii) em caso de não atendimento dos itens (i) e (ii) acima até 25.9.2014, a Petrobrás suspenderia o fornecimento do gás (cláusula 15.1 e subitens do Contrato) e cobraria o débito em juízo. A Diretoria Executiva decidiu ainda submeter a matéria ao Conselho de Administração;

- b) A orientação do Conselho de Administração fazia-se necessária em face das implicações de uma decisão a respeito do assunto;
- c) A alternativa aventada pela Diretoria Executiva, referente ao pagamento integral dos valores inadimplidos com a Petrobras, seria improvável e muito rigorosa;
- d) Na hipótese da apresentação de nova proposta de parcelamento dos valores inadimplidos, a Petrobrás usaria a garantia monetizável para levantar dinheiro no mercado, a fim de reduzir a exposição da Companhia com o Sistema Eletrobras. Todavia, tal alternativa esbarraria na condição em que se encontrava a Eletrobras que não a permitiria oferecer garantias monetizáveis; e
- e) Aventou-se a possibilidade do pagamento parcelado, com prazo razoável e garantia do Tesouro, ao invés de garantia da Eletrobras.

47. Ao final, o Conselho de Administração decidiu enviar a Notificação Extrajudicial para a Amazonas Energia e a Cigás, como devedoras principais, e para a Eletrobras, como fiadora, para: (i) pagamento integral dos valores inadimplidos com a Petrobras; ou (ii) apresentação de nova proposta de parcelamento dos valores inadimplidos, desde que acompanhada de garantia monetizável no mercado financeiro, e aceita pela Petrobras. Orientou, ainda, que fossem tomadas as medidas cabíveis para resguardar os interesses da Petrobras na hipótese do não atendimento dos itens (i) e (ii) acima (fls. 68/69).

48. Em 11.12.2014, a Diretoria Executiva da Petrobras, com base no DIP Finanças nº 277, de 5.12.2014, aprovou, dentre outros, a celebração do Instrumento de Confissão de Dívida com a Amazonas Energia; a celebração de Contrato de Garantia entre a União e a Amazonas Energia, com a interveniência da Petrobras; e a celebração de carta compromisso entre a Petrobras e a Eletrobras.

49. Como visto acima, as tratativas referentes à negociação da dívida com a Amazonas Energia já ocorriam no âmbito dos órgãos sociais da Petrobras, pelo menos, desde março de 2014, tendo a administração da Petrobras ao longo deste período discutido as medidas a serem tomadas com vistas à satisfação de seu crédito, bem como avaliado as implicações de uma decisão a respeito do assunto, notadamente o risco proveniente de eventual interrupção do suprimento de energia no Estado do Amazonas.

50. Assim, pelo teor das discussões havidas nos órgãos sociais da Petrobras, não se pode afirmar que os administradores da Companhia ficaram inertes em face da dívida com a Amazonas Energia.

51. Outra circunstância do caso concreto que parece não ter sido bem avaliada pela Acusação refere-se à conclusão de que a novação de dívida foi financeiramente desvantajosa para a Petrobras, na medida em que a taxa de desconto da dívida da Amazonas Energia deveria necessariamente ter sido superior à SELIC, dado que o risco de crédito da Amazonas Energia e de sua controladora Eletrobras era superior

ao da União. No entender da Acusação, a nova dívida possuiria valor presente líquido inferior aos R\$3,26 bilhões da dívida substituída, que seria líquida e exigível em dezembro de 2014.

52. Tal raciocínio não se aplica no presente caso porque os administradores da Petrobras não estavam, naquele momento, avaliando novas opções de investimentos, oportunidade em que comumente valores presentes líquidos dos potenciais projetos de investimentos são comparados para respaldar uma decisão racional da aplicação dos recursos, mas, pelo contrário, eles buscavam reaver recursos da Companhia por meio de uma negociação de dívida. Nestas circunstâncias, a decisão sobre quais são as melhores condições para a repactuação deve considerar outros aspectos que vão além da análise do maior retorno possível para o capital, pois esta decisão depende especialmente da capacidade de pagamento do inadimplente, que, por óbvio, já se encontra em situação financeira difícil para honrar os termos inicialmente pactuados.

53. Ademais, a análise sobre o valor presente líquido empreendida pela SEP esbarra no limite de atuação da CVM em casos semelhantes, pois compete à Autarquia, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 6.385, de 1976, o dever de avaliar o processo que levou até a decisão da administração. Não cabe ao regulador colocar-se no lugar do administrador e determinar qual deveria ter sido o desfecho ideal para determinado negócio, pois, conforme posição já consolidada no âmbito desta Autarquia¹⁴, não compete à CVM adentrar no mérito da decisão, aplicando-se às circunstâncias a regra da decisão negocial (*business judgment rule*)¹⁵.

54. Ainda sobre o tema, cabe registrar que a própria Acusação não atribuiu responsabilidade aos administradores da Petrobras pelo processo decisório que culminou com a repactuação da dívida com a Amazonas Energia, conforme consta do item 47 do Termo de Acusação. Desta maneira, muito embora tenha sido imputada conduta omissiva ao acionista controlador pelo resultado da repactuação, a Acusação concluiu não dispor de provas suficientes de que os administradores faltaram com o dever de zelar pela equidade da negociação com sociedade sob controle comum.

55. Não obstante, e examinando objetivamente os termos da repactuação, tampouco é possível afirmar com a convicção demonstrada pela Acusação que as condições estipuladas pela renegociação entre a Petrobras e a Amazonas Energia foram de fato desvantajosas para a Petrobras.

56. Como já exposto no relatório, o Instrumento de Confissão de Dívida com a Amazonas Energia foi celebrado em 31.12.2014 e importou no reconhecimento pela devedora da dívida no valor de R\$3,26 bilhões em favor da Petrobras, referente ao fornecimento de gás entre fevereiro de 2013 e novembro de 2014, corrigido e atualizado até 05.12.2014¹⁶. A Amazonas Energia comprometeu-se a liquidar a dívida em 120 prestações mensais e consecutivas (vencendo a primeira em 20.2.2015), atualizadas pela Taxa SELIC.

57. Registre-se que tais condições são muito semelhantes àquelas que já eram negociadas pela Petrobras com a Eletrobras desde, ao menos, março de 2014, como se verifica da leitura dos atos societários antes mencionados e, segundo a Defesa, eram exatamente as mesmas previstas no contrato original e as que seriam provavelmente obtidas caso se optasse pela via judicial.

58. Além disso, a presunção a respeito da liquidez e certeza do crédito detido pela Petrobras em face da Amazonas Energia utilizada para a Acusação afirmar que

a Companhia deveria ter ingressado com uma ação judicial, ao invés de repactuar a dívida, foi bastante diminuída com a informação de que o fornecimento de gás entre as companhias se deu sem a existência de um contrato formal até 2013, conforme consta do extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Petrobras às fls. 71 e 72.

59. A própria área técnica da Petrobras tinha dúvidas a respeito da liquidez e certeza da dívida originária, dando a entender que a cobrança, possivelmente, dar-se-ia por meio de uma ação ordinária de conhecimento, tendo em vista que somente em 2013 fora realizada licitação para o fornecimento de gás à Amazonas Energia, consoante descrito às fls. 58 e 59.

60. Com efeito, a partir da renegociação da dívida, a Petrobras passou a contar com um título executivo extrajudicial apto a amparar ação autônoma de execução, ao passo que antes disso o direito da Companhia sobre aqueles créditos parecia mais incerto, vez que dependeria de uma ação ordinária de cobrança.

61. Acrescente-se que a repactuação também estabeleceu que a União prestaria “garantia fidejussória irrevogável e irreatável” vinculada à contragarantia que deveria ser outorgada à União pela Eletrobras e pela Amazonas Energia até 15.2.2015, caso contrário, passaria a Eletrobras à condição de fiadora e devedora solidária da dívida (cláusulas segunda e quarta). Nesse aspecto, a Acusação salienta que, por ocasião da novação da dívida, a única garantia existente era aquela pessoal prestada pela Eletrobras, pois a possível garantia da União dependia ainda da sua efetiva prestação até 15.02.2015, o que acabou não acontecendo, acrescentando que tampouco haveria à época garantia real, uma vez que o Contrato de Penhor em Garantia¹⁷ só foi celebrado em março de 2015.

62. A existência de uma garantia “monetizável” era uma preocupação da Petrobras, tanto que a celebração do acordo, embora aventada desde o início do ano de 2014, vinha esbarrando na necessidade do reforço da garantia prestada pela Eletrobras. Aliás, por essa razão que se sugeriu a interferência do Tesouro Nacional, conforme demonstram especialmente a ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 8.8.2014 e o extrato da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 29.8.14.

63. A concessão de garantia pela União, por sua vez, não se opera de imediato, na medida em que requer a observância de requisitos legais, notadamente aqueles previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), incluindo os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal por meio da Resolução nº 48, de 2007¹⁸. Inclusive, a necessidade do cumprimento desses requisitos foi ressaltada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por ocasião da análise das minutas contratuais, conforme exposto na Nota PGFN/CAF/Nº 660/2015 (fls. 48/49).

64. De fato, no caso concreto, a garantia fidejussória a ser prestada pela União não se concretizou na data prevista, porém, por motivo imputado à própria Petrobras, que, na data da celebração dos instrumentos contratuais, encontrava-se inscrita no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN¹⁹. E, como disposto no art. 10 da Resolução do Senado Federal acima referida, a União só pode prestar garantia a quem comprove o adimplemento quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos à União, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dela recebidos.

65. Em vista disso, novamente a Petrobras buscou uma solução para a questão, suscitando junto às autoridades governamentais apoio para a implementação dos termos já acordados entre as partes, consoante a Carta Presidência 005, de 14.1.2015, enviada pela Petrobras ao Ministro Chefe da Casa Civil, com cópia para os Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia (fls. 90/92).

66. Nesse contexto é que, em 3.3.2015, os representantes do Tesouro Nacional, do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da Eletrobras e da Amazonas Energia reuniram-se e acordaram que, em substituição à garantia da União, seria celebrado Contrato de Penhor em Garantia por meio do qual seriam penhorados em favor da Petrobras os créditos detidos pela Amazonas Energia junto ao fundo setorial da Conta de Desenvolvimento Energético ("**CDE**")²⁰.

67. Tais créditos originavam-se dos "Contratos de Confissão de Dívida da CDE", celebrados entre a Amazonas Energia e a CDE com o objetivo de repactuar a dívida desta última perante aquela companhia, referente ao atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.111, de 2009, conforme autorizado pelo Decreto nº 8.370, de 10.10.2014.

68. Logo em seguida, em 23.3.2015, a Amazonas Energia e a Petrobras celebraram o Contrato de Penhor em Garantia, no valor de R\$851,4 milhões, posteriormente aumentado para R\$2,1 bilhões, remanescendo a Eletrobras como fiadora e devedora solidária exclusivamente quanto ao montante restante da dívida (R\$1,11 bilhão).

69. Diante do exposto, não se vê, ao contrário do que sustenta a Acusação, qualquer desvantagem pelo fato de o Instrumento de Confissão de Dívida ter sido assinado quando ainda não havia sido efetivada a garantia fidejussória da União, que, como visto, não poderia ser prestada de imediato, por depender do cumprimento de requisitos legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e em Resolução do Senado Federal. Aliás, a garantia fidejussória não foi ao final concedida exatamente pelo descumprimento de um desses requisitos, visto que a Petrobras encontrava-se à época inscrita no CADIN.

70. Resta, assim, que a Petrobras tomou as providências que lhe aparentavam cabíveis para fins de obter a garantia pretendida e assegurar o pagamento da dívida no caso de inadimplemento da devedora. Afinal, tão logo cientificada da impossibilidade da prestação da garantia inicialmente aventada, encaminhou correspondência às autoridades competentes para fins de sanar a questão, o que de fato ocorreu no curto período de dois meses.

71. Destes fatos também não se verifica a existência de provas hábeis a demonstrar uma ingerência da União, como acionista controladora da Petrobras, no processo de tomada de decisão pelos administradores. No caso concreto, não há provas de que a participação dos representantes do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia caracterizou uma participação direta da União no processo da decisão negocial, como supõe a Acusação. Como destacado pela Defesa, estas participações restringiram-se às discussões referentes à concessão da garantia pela União (Tesouro Nacional). E, como visto acima, a existência de garantia "monetizável" era uma preocupação da Petrobras, na condição de credora, no intuito de resguardar os interesses da companhia no caso de inadimplência da devedora.

72. Admitir tal ingerência do controlador no processo de decisão negocial, em verdade, pressupõe uma influência sua sobre os administradores, que, por sua vez, têm o dever de atuar de forma a lograr os fins e no interesse da companhia, não

podendo, ainda que para a defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres, conforme preceitua o art. 154 da lei nº 6.404, de 1976. Em outras palavras, corolário da ingerência indevida do acionista controlador na administração de uma companhia é a responsabilização dos administradores por desvio de finalidade. Neste particular, repise-se que a própria Acusação não atribuiu responsabilidade aos administradores da Petrobras, conforme consta do item 47 do Termo de Acusação.

73. Ainda de acordo com a Acusação, a União teria se beneficiado duplamente, tendo em vista que teria havido, pelos termos desvantajosos da repactuação, uma transferência de “valor” entre sua controlada direta (Petrobras) para a sua controlada indireta (Amazonas Energia), na qual detinha maior participação acionária, bem como um benefício pelo fato de não precisar transferir imediatamente recursos para os Fundos Setoriais (CDE) que seriam utilizados para o pagamento da dívida originária.

74. Contudo, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a União, na condição de controladora da Petrobras, tenha orientado a Companhia em seu exclusivo interesse, em prejuízo dos demais acionistas. Mais que isso, a Acusação não logrou comprovar que a repactuação realizada com a Amazonas Energia tenha sido de fato lesiva para a Petrobras.

75. Como se vê, a situação que se apresenta é bastante diferente daquela verificada nos autos do já mencionado PAS CVM nº RJ2012/1131, em que o Estado de São Paulo foi condenado por ter-se omitido em relação a transações entre a EMAE e Sabesp. A EMAE não recebia qualquer valor em compensação pelo uso da água, e o controlador, mesmo diante das provocações por parte da administração da EMAE e da situação de prolongada fragilidade financeira da companhia, manteve uma postura intencionalmente passiva em relação ao dever previsto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 1976.

76. O que se depreende dos extratos das reuniões realizadas no âmbito da diretoria e dos conselhos fiscal e de administração da Petrobras é que a decisão sobre os termos da repactuação questionada pela Acusação foi tomada pela administração da Petrobras, nos limites de sua competência e sem ingerência indevida da acionista controladora.

77. Em verdade, os elementos constantes dos autos evidenciam que a União interveio quando instada pela administração da Petrobras, primeiro para fins de conceder a garantia fidejussória requerida e, posteriormente, para viabilizar a implementação dos termos já acordados entre as partes, a partir da substituição daquela garantia pelo penhor dos créditos detidos pela Amazonas Energia junto à CDE. A participação da União, portanto, restringiu-se, de acordo com as provas carreadas aos autos, às discussões referentes à concessão da garantia, que, como visto, era uma preocupação da Petrobras, na condição de credora, no intuito de resguardar os interesses da Companhia no caso de inadimplência da devedora.

78. Diante de todo o exposto, voto pela absolvição da União Federal, da acusação de violação ao art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404, de 1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 116. *Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.*

² A existência dessa dívida é reconhecida pela Portaria Interministerial nº 652, de 2014, dos Ministérios da Fazenda e das Minas e Energia.

³ Na nota explicativa nº 15.5 das demonstrações financeiras de 31.12.2014, a administração da Eletrobrás reconhece que a Amazonas Energia é dependente do seu suporte financeiro.

⁴ A dívida originária era R\$2,94 bilhões (fls. 20v).

⁵ O risco de crédito das sociedades do Sistema Eletrobras, que inclui a Amazonas Energia, é tão significativo que justificou, em 2014, o reconhecimento pela Companhia de R\$4,5 bilhões, incluindo saldos a vencer das novas dívidas, que possuem garantia pessoal da Eletrobras, como perdas em créditos de liquidação duvidosa.

⁶ A participação direta e indireta da União no capital social era de 46%, no caso da Petrobras, e de 67,2%, no caso da Eletrobras, em dezembro de 2014.

⁷ Neste sentido ver também o voto preferido pela Diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS 2012/1131, julgado em 26.05.2015. Também sobre o tema vale destacar as palavras do diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2005/1443, julgado em 10.5.2006, o Colegiado decidiu que: “[p]ara dar efetivação aos deveres impostos ao acionista controlador no art. 116, o art. 117 responsabilizou-o ‘pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder’. Dentre as modalidades de exercício abusivo de poder, a Lei 6.404/76 elencou algumas hipóteses que não são consideradas quando da análise do voto do acionista não controlador (art. 117, §1º, ‘e’, ‘f’, ‘g’ segunda parte e ‘h’). Diferentemente dos acionistas não controladores, os acionistas controladores, enquanto possam ser assim considerados, têm obrigações e responsabilidades por atos (**e mesmo omissões, no caso da alínea ‘g’**) não decorrentes do exercício do direito de voto”.

⁸ “Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação.”.

⁹ Itens 9 10 do Memorando nº 57/2015-CVM/SEP/GEA-3, às fls. 240/241.

¹⁰ Voto condutor da Pres. Maria Helena Santana, PAS CVM nº 25/2003, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 25.3.2008.

¹¹ Como, aliás, amplamente reconhecida na doutrina pátria. V., por todos, Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada, vol. 4, São Paulo: Quartier Latin, 2015, 2ª ed., p. 249.

¹² Segundo registrado no extrato da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 25.4.14.

¹³ DIP AFIN 84/2014, de 20.6.2014.

¹⁴ É o que se extrai, por exemplo, do voto proferido pela Diretora-Relatora Maria Helena Santana no PAS CVM nº RJ2005/0097, julgado em 15.3.2007: “Antes de concluir, gostaria de comentar o que foi utilizado pela SEP como razão principal para caracterizar o cometimento de todas as infrações que entendeu serem imputáveis aos indiciados neste processo. Foi considerado pela área técnica que os títulos adquiridos pela TCO contavam com garantias insuficientes, dadas as informações constantes dos autos a respeito da situação econômico-financeira de seus emissores. Em minha análise, não considerei essa motivação, nem entendo que isso tenha feito falta, para chegar às conclusões que proponho. Mas, mais que isso, creio que considerações sobre o mérito de decisões de negócio, em geral, extrapolam o papel do regulador, em sua tarefa de revisão da legalidade dos atos dos administradores de companhia aberta. O regulador deve evitar que sua eventual avaliação seja fator que influencie a análise sobre a legalidade da atuação dos administradores, pois pode observar as decisões tomadas por eles em condições de certa forma mais favoráveis, e sem dúvida bastante distintas das que enfrenta o gestor na hora de fazer escolhas. O gestor de companhia lida com restrições de tempo e de recursos que o levam a dedicar mais ou menos tempo a certas decisões, a realizar estudos mais ou menos aprofundados em cada caso, e isso faz parte de suas responsabilidades. Além disso, ele certamente dispõe de dados que não estão disponíveis para o regulador, os quais considera em suas decisões. Mas a análise da CVM sobre determinado ato de gestão conta com uma grande vantagem, que não seria justo permitir que fosse usada em prejuízo dos administradores: ela é feita de posse da informação sobre o resultado que o ato acarretou. Se a revisão da legalidade de atos de administração, portanto, puder avançar em aspectos do mérito das decisões, estaremos correndo o risco de reduzir o dinamismo de nossas companhias abertas, pois estará sendo incentivada uma postura extremamente avessa ao risco por parte dos seus administradores.”

Vide, dentre outros, os seguintes PAS: 25/2003 (julgado em 25.3.2008), 8/2005 (julgado em 12.12.2007), 21/2004 (julgado em 15.5.2007) e 9/2003 (julgado em 25.1.2006).

15 BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a *Business Judgment Rule*. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 107 e 108. “A *business judgment rule* é dos temas mais importantes que permeiam o regime de responsabilidade dos administradores de companhias. Como se viu, um dos principais desafios enfrentados pelo legislador ao estabelecer este regime é encontrar o equilíbrio ideal entre (i) a necessária prevenção de eventuais abusos da posição de confiança detida por diretores e conselheiros perante as companhias e (ii) a também necessária liberdade e discricionariedade que eles

devem ter para gerir os negócios sociais. Se é verdade que administradores devem responder por danos que causarem ao patrimônio de companhias de forma culposa ou dolosa, também é verdade que a atividade por eles executada está sujeita a erros cometidos sem culpa que podem prejudicar essas sociedades. Caso se permita a responsabilização de diretores e conselheiros por esses erros, profissionais conscientes e capazes não se aventurarão em cargos de administração de companhias. Temendo sua responsabilização, aqueles poucos que ainda remanesceriam evitariam a tomada de riscos, que é essencial para a consecução de lucros, como exposto no primeiro capítulo deste trabalho. Também não seria surpreendente se acionistas insatisfeitos com a gestão, mas sem participação societária suficiente para substituir os administradores, passassem a ajuizar ações contra eles. Dessa forma, mesmo com pouca expressividade no capital social, passariam a intervir indevidamente no mérito dos atos de gestão, que cabem aos diretores e conselheiros, e não aos sócios. É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à legalidade do procedimento decisório. Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que administradores responderão pessoalmente pelos danos que causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões negociais, é a business judgment rule o instrumento que contribui da maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da administração de companhias".

¹⁶ A dívida originária era R\$2,94 bilhões (fls. 20v).

¹⁷ Para maiores detalhes, ver item 57.

¹⁸ Dispõe sobre os limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

¹⁹ Segundo relatado na Carta Presidência 005/2015, de 14.1.2015, referente à "Dívida do Sistema Eletrobras com o Sistema Petrobras", enviada pela Petrobras ao Ministro Chefe da Casa Civil, com cópia para os Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia (fls. 90/92).

²⁰ Informação prestada pelo DRI da Petrobras à fl. 60.

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10677 realizada no dia 07 de fevereiro de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM e da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10677 realizada no dia 07 de fevereiro de 2017.

1. Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator Henrique Machado, uma vez que os elementos nos autos não constituem prova suficiente para caracterizar a suposta infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 1976 ("Lei 6.404").

2. A meu ver, somente seria possível responsabilizar a União Federal ("União") se restasse comprovado, no mínimo, um comportamento deliberadamente ativo ou passivo:

- (i) com a finalidade de aceitar e perpetuar o inadimplemento da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. ("Amazonas Energia") que deu origem à dívida; ou

- (ii) privilegiando, no contexto da repactuação de tal dívida, seu interesse próprio em detrimento da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (ou “Companhia”) ou de seus acionistas.

3. É evidente que a inadimplência da Amazonas Energia gerou prejuízos à Petrobras durante o período em que houve a prestação de serviços de fornecimento de gás natural sem contrapartida.

4. O que não ficou evidente, contudo, foi que essa inadimplência tenha ocorrido por força de uma deliberada omissão da União. Não se comprovou a atuação intencional ou coordenada de representantes da União para que a Petrobras deixasse de adotar medidas para fazer cumprir as obrigações convencionadas nos contratos de distribuição.

5. Considerando que a Amazonas Energia é subsidiária integral da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, também controlada pela União, a acusação inferiu que a União teria feito uso da Petrobras, em uma ponta da operação, para se esquivar de custos maiores que lhe competiriam na outra ponta dessa transação.

6. Especialmente em transações envolvendo partes relacionadas, quando se pode vislumbrar interesses potencialmente conflitantes entre o acionista controlador e a companhia, suposições como essa não são inverossímeis.

7. Ocorre que, pelos autos, entendo não ser possível concluir, de forma segura, que isso tenha de fato ocorrido no presente caso.

8. O cenário possivelmente seria outro diante de indícios mais robustos para corroborar essa tese, tais como documentos, atas, e-mails ou mesmo relatos de envolvidos, no sentido de que representantes da União “acordaram”, ou “aceitaram”, a inadimplência da Amazonas Energia. Ou mesmo elementos apontando que a União ignorou ou minou, de algum modo, a atuação de administradores e responsáveis por adotar medidas para sanar esse inadimplemento.

9. Nessas hipóteses, estaríamos diante de uma conduta altamente reprovável, não só configurando o exercício abusivo do poder de controle por parte da União (em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404), mas também indo na contramão de todos os recentes movimentos voltados ao aprimoramento da governança das empresas estatais de capital aberto, como muito oportunamente lembrado pelo Diretor-Relator.

10. A propósito, em situação com características similares (PAS CVM nº RJ2012/1131, julgado em 26.05.2015), o Colegiado da CVM fixou entendimento de que o interesse público referido no art. 238 da Lei 6.404 em nada atenua o dever dos acionistas controladores de resguardar lealmente os interesses da companhia, em respeito aos demais acionistas¹.

11. Ocorre que, naquele precedente, diferentemente do presente caso, restou comprovada uma postura intencionalmente omissa do Estado de São Paulo, ente estatal controlador, perpetuando uma situação em que os acionistas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE (sua controlada) seguiram sofrendo prejuízos em decorrência de relação entre a EMAE e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (também controlada pelo Estado de São Paulo), não obstante os diversos questionamentos dos administradores, conforme documentação acostada nos autos daquele processo.

12. Tratando mais especificamente da atuação da União na repactuação da dívida gerada pela inadimplência da Amazonas Energia, também não verifico a comprovação do ilícito apontado, por duas principais razões.

13. De um lado, pois é absolutamente possível que, em renegociações de dívida, discuta-se a redução de juros e mesmo a taxa de atualização dos valores envolvidos, considerando, dentre inúmeros fatores, a capacidade de pagamento do devedor e a perspectiva de recebimento do valor original.

14. De outro, porque a decisão negocial dos administradores em situações como essa apenas poderia ser contestada se ausentes os requisitos da já consolidada *business judgment rule*² (isto é, se a decisão não fosse desinteressada, informada e refletida).

15. E essa segunda razão me leva a ponderar sobre outro pressuposto da tese acusatória: a presumida ingerência da União, controladora, sobre os administradores da Petrobras.

16. As figuras do administrador e do acionista controlador, em regra, não se confundem. E creio que as eventuais medidas para sanar a inadimplência da Amazonas Energia quanto para a própria repactuação da dívida se inserem, em tese, no âmbito de decisões negociais tomadas pelos administradores³.

17. A conduta dos administradores, a quem cumpre observar os deveres fiduciários previstos nos artigos 153 e seguintes da Lei 6.404, poderia ter sido questionada, especialmente em face do longo período de inadimplência por parte da Amazonas Energia. Evidentemente, a eventual configuração de infração dependeria de uma análise da conduta dos administradores à luz de tais deveres e das circunstâncias fáticas presentes, inclusive considerando em que medida e como sua atuação pode ter sido guiada ou influenciada pela União. Entretanto, essa análise não compõe o escopo deste processo sancionador.

18. Assim, pelo exposto, inexistindo maiores evidências concretas de que os representantes da União interferiram nas decisões negociais dos administradores da Petrobras, e tendo em vista que não se logrou demonstrar, com a razoável certeza que se requer uma condenação, (i) como a União teria permitido o inadimplemento que deu origem à dívida, ou (ii) como a repactuação teria sido feita em seu benefício próprio em detrimento da Petrobras, entendo, em linha com o voto condutor, que a acusação de infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404 não merece prosperar.

É como voto.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

¹ CVM, PAS CVM nº RJ2012/1131, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 26.05.2015.

² Dentre tantos outros, cite-se o PAS CVM nº 21/2004, Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 15.05.2007.

³ A respeito, aliás, como aponta o Diretor-Relator, este Colegiado recentemente manifestou o entendimento de que, especialmente em operações com potencial conflito de interesses, como aquelas envolvendo partes relacionadas, cabe à administração conduzir a transação com plena independência, não sendo desejável qualquer ingerência por parte do acionista

controlador (CVM, PAS nº RJ2012/11199, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 22.03.2016).

Encerramento da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10677 realizada no dia 07 de fevereiro de 2017.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela absolvição da União Federal da acusação de suposta infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que, com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE